

1500221-85.2021.8.26.0546

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PAULO HENRIQUE ADUAN CORREA

Comarca: Artur Nogueira

Foro: Foro de Artur Nogueira

Vara: 1ª Vara Judicial da Comarca de Artur Nogueira

Data de Disponibilização: 11/04/2022

... em 19/04/2018, DJe 30/04/2018)

"Tráfico de Drogas - Recurso ministerial visando a condenação do apelado pelo tráfico de drogas - Possibilidade - Nulidade da prisão realizada por guardas municipais afastada - Agentes públicos que, como qualquer outro cidadão, têm o poder de prender quem quer que se encontre em flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP - Prova ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Artur Nogueira

Foro de Artur Nogueira

Vara Única

Rua 13 de Maio, 140, Artur Nogueira - SP - cep 13160-170

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

1500221-85.2021.8.26.0546 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500221-85.2021.8.26.0546

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

RENAN CÉSAR BARBOSA SCUSSEL

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO HENRIQUE ADUAN CORREA

Vistos.

RENAN CÉSAR BARBOSA SCUSSEL, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pelos fatos melhor descritos na exordial acusatória de fls. 02/04.

O réu foi notificado (fl. 115) e, por meio de seu Defensor constituído, apresentou defesa preliminar (fls. 117/123).

O recebimento da denúncia ocorreu em 05/11/2021 (fl. 131/132) e o réu foi citado (fl. 142).

Durante a instrução foram inquiridas duas testemunhas, sendo que, ao final, o réu foi interrogado.

Em sede de alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a procedência integral da pretensão punitiva.

A Defesa, por sua vez, requereu a nulidade de todas as provas, porque decorrentes de ação feita pela Guarda Municipal, e pela ilegalidade da prisão em flagrante. No mérito, requereu a desclassificação do crime de tráfico para aquele previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, afasto as preliminares de nulidade processual aventadas pela Defesa técnica.

Com efeito, a prisão em flagrante efetuada pelos guardas municipais não constitui ato ilegal, estando em conformidade com o que prevê o artigo 301 do Código de Processo Penal.

Nesse mesmo sentido:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DOS GUARDAS MUNICIPAIS PARA EFETUAR PRISÃO EM FLAGRANTE. PERMISSIVO DO ART. 301 DO CPP. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, de modo que inexistente óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. Precedentes.

2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

3. No presente caso, a segregação cautelar foi decretada pelo Tribunal estadual, em razão da periculosidade do paciente, evidenciada (i) pelo efetivo risco de voltar a cometer delitos, porquanto a ré já possui condenação por tráfico de drogas e (ii) pela quantidade de entorpecente apreendido (147,23g de maconha, 21, 51g de crack e 104,82g de cocaína). Prisão preventiva justificada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública. Precedentes.

4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

5. Recurso ordinário improvido".

(RHC 94.061/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018)

"Tráfico de Drogas – Recurso ministerial visando a condenação do apelado pelo tráfico de drogas – Possibilidade – Nulidade da prisão realizada por guardas municipais afastada – Agentes públicos que, como qualquer outro cidadão, têm o poder de prender quem quer que se encontre em flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP – Prova segura – Tráfico de drogas demonstrado – Condenação necessária – Dosimetria – Aumento da pena-base em função dos péssimos antecedentes do acusado – Privilégio incabível ante a significativa quantidade e variedade de drogas – Regime semiaberto – Recurso provido".

(TJSP; Apelação Criminal 1502947-96.2020.8.26.0536; Relator (a): André Carvalho e Silva de Almeida; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Praia Grande - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/09/2021; Data de Registro: 21/09/2021)

Importa considerar, ainda, que eventuais irregularidades ou ilegalidades da fase extrajudicial da persecução penal, momento da persecução penal em que ainda não se estabeleceu a relação jurídica processual, não têm o condão de contaminar o processo.

Não bastasse isso, tem-se que o art. 5º, incisos IV, XIV, XVI, e seu parágrafo único, da Lei nº 13.022/2014, autoriza a atuação da Guarda Municipal diante de situações envolvendo a prática de infrações penais, especialmente naquelas que envolvem hipótese de flagrante delito, razão pela qual nenhuma nulidade há a ser reconhecida.

Da mesma forma, nenhuma ilegalidade há no fato de guardas municipais terem ingressado na residência do réu, em cujo interior localizaram as porções de drogas. De fato, o que a jurisprudência majoritária exige para o ingresso no domicílio do suspeito sem mandado judicial é a existência de fundadas razões (justa causa), aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas, de maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.

No caso em tela, verifica-se que os guardas somente ingressaram no imóvel após encontrarem, no celular de um usuário que havia acabado de sair do local, um print que continha um anúncio de venda de entorpecentes publicado pelo réu, tendo o usuário alegado que havia ido ao imóvel para adquirir 25g de maconha pelo valor de R\$ 100,00.

Ora, tais circunstâncias fáticas autorizavam o imediato ingresso dos guardas ao imóvel, o qual, diga-se de passagem, foi autorizado pelo acusado, conforme reconheceu em seu interrogatório extrajudicial, não sendo razoável que se exigisse a chegada de policiais militares para, somente então, proceder-se à busca domiciliar. A urgência e os riscos existentes autorizavam a medida que, portanto, mostrou-se razoável.

Diante disso, não se afiguraria legítimo anular todas as provas acostadas aos autos, tal como pretende a Defesa técnica, especialmente se se considerar que o precedente por ela mencionado, qual seja, o HC nº 616.584, julgado pelo C. STJ, não é vinculante e, com a devida vênia, não encontra amparo no que prevê a CF (art. 5º, XI) e na jurisprudência majoritária do E. TJSP sobre o tema.

Recorde-se que o tráfico de drogas tem caráter permanente, o que permite a prisão em flagrante enquanto estiverem sendo realizadas as condutas previstas no tipo penal. Neste caso, o estado de flagrância dispensa o consentimento do morador ou mesmo a prévia ordem judicial para ingresso forçado no domicílio.

Nesse sentido:

"Apelação. Tráfico de drogas. Recursos do Ministério Público e da Defesa. 1. Preliminar. Arguição de nulidade das provas. Guardas municipais que não estão investidos de função reservada à Polícia. Realização de busca pessoal em contexto de prisão em flagrante delito. Justa causa para a medida. Ilegalidade afastada. Precedentes. 2. Ilicitude probatória não configurada. Depoimentos firmes dos guardas civis indicando as circunstâncias da prisão em flagrante do acusado. Diligência no interior do imóvel que foi precedida da fuga do réu que dispensou um tijolo de maconha em via pública tentando se esconder no interior de um apartamento onde havia mais entorpecentes. Certeza visual e atualidade da situação flagrancial antes do ingresso no domicílio onde o restante dos entorpecentes e os petrechos foram encontrados. Configuração de suficiente justa causa quanto à situação de flagrante delito. Ingresso no domicílio amparado pelo permissivo constitucional. Ausência de violação à garantia da inviolabilidade domiciliar. 3. Mérito. Condenação adequada. Materialidade demonstrada pela apreensão dos entorpecentes e pela prova técnica. Autoria certa. Relatos convergentes dos guardas civis narrando as circunstâncias da prisão em flagrante do acusado. Réu confesso. Destinação comercial comprovada. 4. Dosimetria. Pena-base fixada acima do limite mínimo diante da natureza dos entorpecentes. Apreensão de cocaína e crack. Circunstância preponderante à luz do art. 42 da Lei de Drogas. Confissão espontânea corretamente reconhecida. Impossibilidade de aplicação da agravante genérica dada pela calamidade pública. 5. Tráfico privilegiado reconhecido em sentença. Pleito ministerial objetivando a sua cassação. Cabimento. Expressiva quantidade de drogas apreendidas em poder do acusado. Encontro de tijolos de maconha e cocaína à granel que seriam fracionados em quantidades menores e inseridos no mercado ilícito de drogas. Apreensão de diversos petrechos utilizados no acondicionamento e embalo das substâncias. Circunstâncias caracterizadoras da dedicação às atividades ilícitas.

Regime fechado mantido. 6. Pleito objetivando a cassação do direito de recorrer em liberdade. Descabimento. Acusado primário e portador de bons antecedentes. Encerramento da instrução. Inexistência de elementos indicativos de que o réu pretendesse frustrar a futura aplicação da lei penal. 7. Recurso ministerial parcialmente provido. Improvimento do recurso defensivo". (TJSP; Apelação Criminal 1501416-42.2021.8.26.0567; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/03/2022; Data de Registro: 14/03/2022)

"Apelação - Tráfico e cultivo de matéria prima para a confecção de entorpecentes - Preliminar - Nulidade - Ilegalidade de provas - Alegada violação de domicílio - Delito permanente - Prescindível o mandado de busca e apreensão - Fundadas razões que justificaram o ingresso no local (justa causa) - Preliminar rejeitada - Materialidade e autoria demonstradas - Firmes e coerentes os depoimentos dos guardas municipais - Intuito mercantil comprovado nos autos - Impossibilidade de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas - Alegação de uso desvinculada do conjunto probatório - Condenação mantida - Penas adequadamente fixadas e bem fundamentadas - Redutor do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 aplicado na origem - Regime aberto - Pretendida redução da pena de multa - Descabimento - Multa que atende aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade - Pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e questões afetas à detração são de competência do Juízo das Execuções - Preliminar rejeitada, Recurso desprovido". (TJSP; Apelação Criminal 0001117-59.2018.8.26.0272; Relator (a): Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapira - 1ª Vara; Data do Julgamento: 12/12/2021; Data de Registro: 12/12/2021)

Outro não é o entendimento do C. STJ sobre o tema:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO: FUNDADAS SUSPEITAS. ATUAÇÃO DE GUARDAS MUNICIPAIS. POSSIBILIDADE. FLAGRANTE DELITO. PATRULHAMENTO QUE DENOTA DILIGÊNCIA PRÉVIA E FUNDADA SUSPEITA NO CASO CONCRETO. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA AFASTAR AS CONCLUSÕES DA ORIGEM. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE IN CASU. MODUS OPERANDI QUE REFLETE A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício. II No caso vertente, a fundada suspeita residiu não apenas nas diversas denúncias recebidas e no fato de que o imóvel seria destinado à traficância. Em patrulhamento, como diligência prévia à abordagem, ainda fora da residência, por uma fresta, foi verificado que o paciente se encontrava sentado ao lado de drogas e petrechos destinados à prática criminosa. Ademais, todo o material efetivamente apreendido somente reforçou a necessidade da atuação estatal para conter o flagrante delito. III - Com efeito, assente na jurisprudência deste Tribunal Superior que, "Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, de modo que inexistente óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. Precedentes" (HC n. 421.954/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 2/4/2018). (...)  
Habeas corpus não conhecido". (HC 696.972/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF), QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do delito de tráfico ilícito de drogas restou demonstrada por meio dos laudos químico-toxicológicos de fls. 88/92, que atestaram pericialmente ser maconha a substância tida em depósito pelo acusado na data dos fatos, estando relacionada na Portaria SVS/MS 344, de 12 de maio de 1998.

A autoria delitiva, de igual sorte, é indubitável.

O réu, em juízo, alegou que as drogas encontradas em sua casa se destinavam apenas ao seu consumo.

Ocorre que a versão judicial por ele apresentada não encontra respaldo no robusto conjunto probatório acostado aos autos.

Isso porque o guarda municipal Rodrigo Cândido Gonçalves asseverou que, na data dos fatos, estava em patrulhamento de rotina quando abordou um homem que havia acabado de sair da casa do réu. Nada de ilícito foi encontrado em seu poder. Referido rapaz mencionou que havia ido até o local para adquirir uma porção de maconha do acusado pesando 25 gramas ao preço de R\$ 100,00. O usuário mostrou ao depoente um print tirado de um perfil de rede social do réu no qual este informava que havia chegado droga "da boa". Posteriormente, o depoente encontrou RENAN saindo do imóvel, ocasião em que foi abordado. Questionado sobre a procedência da denúncia, o réu respondeu que era usuário e disse que tinha droga em sua residência, tendo autorizado o ingresso dos guardas ao imóvel, em cujo interior foram encontradas 3 porções de maconha em um pote de margarina. Duas das porções pesavam 25 gramas e a outra, 22 gramas. Também foram encontrados R\$ 564,00 em espécie e uma balança de precisão. O réu era conhecido dos meios policiais por seu envolvimento no tráfico. No mesmo sentido foi o depoimento do guarda Carlos Eduardo Paschoal.

Da análise das provas coligidas aos autos permite-se concluir, com absoluta certeza, que a droga tida em depósito pelo réu realmente era destinada à entrega ao consumo de terceiros.

Com efeito, conforme se depreende do depoimento dos guardas ouvidos em juízo, verifica-se que, na data dos fatos, um usuário fora visto saindo da casa do réu, sendo que, ao ser abordado, confidenciou que havia ido ao local para adquirir 25 gramas de maconha ao preço de R\$ 100,00.

O print de um anúncio feito pelo réu indicando que havia recebido entorpecentes encontra-se às fls. 26, sendo certo que, tal elemento de prova, somado à apreensão de uma balança de precisão no local e à efetiva localização de duas porções de maconha pesando exatamente 25 gramas são circunstâncias que comprovam que o réu realmente oferecia maconha a terceiros valendo-se de sua rede social, sendo este o motivo pelo qual o usuário foi até sua casa na data dos fatos.

Esse cenário fático desmonta a tese criada pelo réu de que seria apenas um usuário, não prosperando a alegação de que o anúncio de fls. 26 teria sido feito por outro indivíduo também chamado Renan Barbosa, haja vista que o usuário abordado pelos guardas municipais fora visto saindo da casa do réu, e não de terceiros.

Verifica-se, assim, que o contexto fático narrado pelos agentes públicos merece credibilidade, especialmente por não se vislumbrar qualquer razão que justificasse eventual intenção deles em prejudicar injustamente o acusado, o qual, diga-se de passagem, sequer apontou possuir problemas pretéritos com os guardas que o detiveram que justificasse eventual tese de 'perseguição'.

Registre-se, outrossim, ser despiciendo para a caracterização do crime de tráfico que o agente seja surpreendido efetivamente comercializando as substâncias ilícitas, tendo o legislador feito expressa menção ao simples ato de o indivíduo "guardar" ou de "ter em depósito" o entorpecente, desde que haja a finalidade de comercializá-lo a terceiros, o que restou sobejamente demonstrado nos autos.

Dessa forma, estando verificadas a materialidade e autoria delitivas, a condenação dos acusados pela prática do crime de tráfico de drogas é medida de rigor.

Superadas tais questões, resta apreciar o cabimento da incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

No caso em apreço, mostra-se viável seu reconhecimento, devendo a minorante incidir em seu patamar máximo, qual seja, 2/3 (dois terços), eis que o acusado é primário e ostenta bons antecedentes, não havendo nenhuma comprovação de que integre

organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas.

Passo, então, à fixação da pena corporal a ser aplicada ao réu, com observância do sistema trifásico adotado pelo Código Penal (artigo 68).

Na primeira fase, em respeito ao que determina o artigo 42 da Lei de Drogas e ao artigo 59 do Código Penal, reputo não haver circunstância judicial desfavorável, razão pela qual fixo a pena-base em 5 anos de reclusão, e 500 dias-multa, cada qual no mínimo legal.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, razão pela qual mantenho a pena provisória no patamar mínimo.

Na terceira fase, incide a causa de diminuição de pena contida no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, em seu patamar máximo, qual seja, 2/3 (dois terços), razão pela qual a pena definitiva deve ser fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa.

Dada a falta de elementos probatórios acerca da situação econômica do acusado, fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do montante do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Dada a falta de elementos probatórios acerca da situação econômica do acusado, fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do montante do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o aberto, conforme prevê o artigo 33, §2º, "c", do CP, tendo em vista o quantum da pena imposta ao réu.

Considerando-se que: (i) o réu não é reincidente em crime doloso; (ii) o ilícito não foi praticado mediante violência ou grave ameaça à pessoa; (iii) apresenta condições pessoais favoráveis e (iv) a pena fixada foi inferior a quatro anos, com fundamento no art. 44, § 2º, do Código Penal, Diante disso, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritiva de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo prazo de duração da pena privativa de liberdade, à razão de 8 (oito) horas semanais, a ser cumprida na forma do art. 46 do CP em dias, horários e locais a serem estabelecidos na fase de execução, nos termos do artigo 149 da LEP, e proibição de frequentar bares e casas de prostituição pelo período de 1 ano e 8 meses.

As penas restritivas de direitos foram assim fixadas por se mostrarem as mais adequadas diante das aptidões e condições pessoais do acusado, assim como por bem atenderem às finalidades de retribuição e ressocialização pela pena.

Deixo de conceder sursis em virtude da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Inviável, pelo mesmo motivo, a concessão do sursis, nos termos do art. 77, II, CP.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu RENAN CÉSAR BARBOSA SCUSSEL, qualificado nos autos, à pena corporal de 1 ano 8 meses de reclusão, e 166 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser atualizado em sede de execução, como incurso nas penas cominadas no artigo 33, caput, e §4º, da Lei nº 11.343/06, e substituo a pena corporal por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo prazo de duração da pena privativa de liberdade, à razão de 8 (oito) horas semanais, a ser cumprida na forma do art. 46 do CP em dias, horários e locais a serem estabelecidos na fase de execução, e na proibição de frequentar bares e casas de prostituição pelo prazo de 1 ano e 8 meses (artigo 47, inciso IV, CP).

Defiro-lhe o direito de recorrer em liberdade, haja vista ter sido fixado regime aberto para o cumprimento da pena.

Autorizo a incineração da substância entorpecente, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova, que deverá ser destruída após o trânsito em julgado.

Porque não comprovada a origem espúria do dinheiro apreendido na casa do réu, defiro a restituição do valor de R\$ 564,00.

Transitada esta em julgado, anote-se a condenação definitiva no Sistema Informativo Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012, da E. Corregedoria Geral de Justiça (art. 372 das NSCGJ), com a posterior expedição da respectiva Guia de Recolhimento.

Custas na forma da lei, cuja exigibilidade fica suspensa.

Publicada em audiência. Saem os presentes intimados.  
Artur Nogueira, 11 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA